

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5073642-09.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: BIANCA AGUILAR MACHADO (AUTOR)

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - DIREITO À SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MONITOR FREESTYLE® LIBRE E SENSOR DE FREESTYLE LIBRE® PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO I - APARELHO E ACESSÓRIOS PRETENDIDOS, EMBORA INDICADOS AO QUADRO CLÍNICO, NÃO SÃO ESSENCIAIS AO TRATAMENTO DA AUTORA (AINDA QUE INEGÁVEIS A PRATICIDADE, O CONFORTO E A QUALIDADE DE VIDA), NÃO SE JUSTIFICANDO O DISPÊNDIO DE ELEVADO VALOR - FORNECIMENTO GRATUITO PELO SUS DE OUTROS MEIOS DE MONITORAMENTO DA GLICEMIA - RECOMENDAÇÃO PRELIMINAR DA CONITEC DE NÃO INCORPORAÇÃO DO SISTEMA FLASH DE MONITORIZAÇÃO DE GLICOSE - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, de forma a manter a sentença proferida pelo juízo de origem. Sem condenação ao pagamento das custas, haja vista a isenção de que goza a parte recorrente, pelo benefício da gratuidade de justiça (art. 4º, II, da Lei 9.289/96). Condene a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, valor este que terá sua exigibilidade suspensa, haja vista tratar-se de beneficiário da gratuidade de justiça. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2025.

5073642-09.2024.4.02.5101

510015300277 .V3

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5073642-09.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: BIANCA AGUILAR MACHADO (AUTOR)

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação dos réus ao fornecimento dos insumos Monitor FreeStyle® Libre e Sensor de FreeStyle Libre®, conforme prescrição médica.

Sustenta a recorrente, em síntese, que necessita dos insumos prescritos pelo médico assistente, ante o quadro de labilidade glicêmica.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Rio de Janeiro.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça.

A Constituição Federal, em seu art. 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, do que decorre, em princípio, uma solidariedade entre os entes federativos, no que diz respeito à sua prestação. Esse regime de responsabilidade solidária instituído pela Constituição inclui, porque indissociável do dever constitucional de todos os entes federativos de assegurar o direito fundamental à saúde, o fornecimento gratuito de medicamentos e a realização de exames às pessoas que não tenham condições financeiras para o custeio.

Inicialmente, parece-me que, uma vez constatada a necessidade de um tratamento médico para uma pessoa que não tenha condições de custeá-lo, em princípio se impõe ao Estado, em regime de solidariedade entre os entes federativos das três esferas, uma atuação positiva, no sentido de propiciar o tratamento exigido para a preservação de sua saúde, não havendo, neste tocante, margem de discricionariedade para o administrador, senão vinculação que decorre do art. 196 da Constituição Federal.

Deste entendimento não destoa a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgado abaixo colacionado:

ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DE INTERESSES OU DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1º DA LEI N. 1.533/51. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SÚMULA 83/STF.

1. Não merece prosperar o recurso quanto à afronta ao art. 1º da Lei 1.533/51. O fundamento da inexistência da demonstração do direito líquido e certo não é apropriado em recurso especial, visto que demandaria o reexame de provas. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2. Qualquer um dos entes federativos - União, estados, Distrito Federal e municípios - tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.

Agravo regimental improvido.

(STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp 609.204/CE, Rel. Min. Humberto Martins, julg. de 16/12/2014, DJe de 19/12/2014)

Embora haja um dever solidário dos entes federados em prover uma assistência integral à saúde, tal qual exposto anteriormente, não se ignora que uma mesma doença possa ser tratada de diversas formas e com diferentes medicamentos, sendo a definição do tratamento adequado a cada caso uma questão de ordem médica e não propriamente de ordem jurídica. Assim, a escolha da alternativa terapêutica adequada a cada doença, quando seu tratamento é feito pelo Sistema Único de Saúde, cabe em princípio ao corpo médico do sistema único de saúde, tal qual estruturado na legislação, devendo tais escolhas ser em princípio prestigiadas pelo Poder Judiciário, na medida em que embasadas em estudos técnicos na área de medicina.

No entanto, embora a escolha do administrador, com base em estudos técnicos, deva ser em princípio prestigiada, não está o Judiciário a ela absolutamente adstrito ou impedido de atuar supletivamente, caso haja nos autos indicativo de que a terapêutica oferecida não tem se mostrado adequada ou suficiente, havendo outras alternativas disponíveis. Entender de modo contrário seria retirar do Poder Judiciário a atribuição de tutelar os direitos fundamentais, em flagrante violação à Constituição.

O exame da questão passa pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, na STA em AgRg 175, onde aquele explicou que o Sistema Único de Saúde filiou-se à corrente da "Medicina com base em evidências", de modo que **um medicamento ou tratamento em desconformidade com o Protocolo deve ser visto com cautela**, pois tende a contrariar consenso científico vigente. Mais do que isso: a gestão do SUS, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às ações de saúde, só se torna viável mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos (naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. Obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada.

Dessa forma, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente.

Com isso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o deferimento pelo Judiciário de medicamento extraordinário fora do âmbito do SUS, deve ficar restrito a hipóteses de rara e especial excepcionalidade:

(a) quando a enfermidade do paciente não for tratada pelo SUS, ou;

(b) quando o tratamento/medicamento disponibilizado pelo SUS não tiver eficácia comprovada no caso concreto.

Caso não se inclua nestas hipóteses, pelo fato de o SUS disponibilizar gratuitamente outros medicamentos para o tratamento da enfermidade, não há que se falar em deferimento pelo Judiciário, sob pena de prejudicar, conforme já explicitado, o acesso universal e isonômico à saúde. E isto porque a opção pelo medicamento listado leva em consideração outros fatores: o custo, a eficácia comprovada e a incidência sobre a patologia tratada, de modo a beneficiar a maior parte da população.

Conclui-se, portanto, que é necessário demonstrar que o tratamento fornecido pelo SUS não é adequado para controle da enfermidade da parte requerente para que, então, possa se fugir ao padrão e deferir terapia diversa, não havendo margem para escolha de tratamento que mais lhe aprouver, desconsiderando as terapias já ofertadas pela Administração Pública, a partir da mera discricionariedade médica, ainda que o profissional esteja vinculado ao SUS.

O Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em sede de representativo de controvérsia (tema 106), no sentido de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença **cumulativa** dos seguintes requisitos:

(a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(c) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.

(grifei)

Em 26/09/2024, em sede de repercussão geral, no âmbito do RE 566471, Redator do acórdão: MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO, o STF fixou as seguintes teses (**Tema 6 e 1234 da repercussão geral** - RE. DJE divulgado em 27/09/2024, publicado em 30/09/2024.):

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficial aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Por fim, determinou, tal como no Tema 1.234, que essas teses sejam transformadas em enunciado sintetizado de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação (Enunciado publicado no DJE e no DOU em 03/10/2024):

Súmula vinculante nº 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Ademais, no tocante à competência, foi destacado o seguinte no referido Tema 1.234:

I - Competência.

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

Destaca-se, todavia, que no tocante à competência, houve modulação dos efeitos, de modo que somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 18/09/2024, não haverá alteração da competência.

No mais, a tese do Tema 6 do STF estabelece uma regra geral: a ausência de um medicamento nas listas oficiais do SUS, em princípio, impede seu fornecimento por decisão judicial (item 1 da tese). Essa diretriz reflete uma deferência judicial às políticas públicas de saúde definidas pelo Poder Executivo, considerando que as listas são elaboradas com base em análises técnicas fundamentadas em critérios técnico-científicos e de custo-efetividade, e não de forma casuística.

Todavia, o STF também definiu os parâmetros que permitem exceções a essa regra, conforme disposto no item 2 da tese:

1. A comprovação de negativa administrativa prévia;
2. A demonstração de ilegalidade ou omissão no processo de incorporação do medicamento;
3. A inexistência de alternativas terapêuticas no SUS;
4. A comprovação científica robusta da eficácia e segurança do medicamento;
5. A demonstração da imprescindibilidade do tratamento;
6. A comprovação da hipossuficiência financeira do paciente.

Dos laudos médicos acostados (Ev. 1.2, fls. 13/14 e Ev. 3.2), verifica-se que a parte autora é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, diagnosticada aos 8 (oito) anos de idade. Apesar de fazer uso de análogos de insulina, apresenta descontrole glicêmico, de modo que foi indicado o uso de sensor Free Style Libre.

Conforme parecer emitido pelo Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde - NAT, em Evento 12 dos autos relacionados nº 5076085-30.2024.4.02.5101 (recurso de medida cautelar), o aparelho e o monitor FreeStyle® Libre, apesar de estarem indicados para o quadro clínico da parte autora, não são imprescindíveis. Não se configura item essencial no tratamento, pois pode ser realizado através do monitoramento da glicemia da forma convencional (glicemia capilar), padronizada pelo SUS.

Como se vê, embora indicados ao caso do autor, os insumos pretendidos não são essenciais ao tratamento da parte autora (ainda que inegáveis a praticidade, o conforto e a qualidade de vida) que justifique o dispêndio de elevado valor direcionado a uma única pessoa em detrimento dos demais administrados, ao passo que existem métodos eficazes de aferição da glicemia e de administração de insulina padronizados pelo SUS.

Cabe salientar a informação do parecer do NAT, no sentido de que a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, por meio do Programa de Hipertensão e Diabetes (HIPERDIA)¹, disponibiliza gratuitamente insulinas e insumos indicados para tratamento e monitorização da glicemia da Diabetes Tipo I, como glicosímetro, fitas para determinação da glicemia, seringas, lancetas e lancetadores.

Ademais, houve incorporação ao SUS das insulinas de ação rápida e de ação lenta para tratamento da Diabetes Mellitus tipo I, conforme critérios definidos no PCDT para a referida doença, com fornecimento através do CEEAF, bastando que o paciente efetue o cadastro.

Destaco, ainda, que houve proposta de incorporação do Sistema Flash de monitorização da glicose por escaneamento intermitente (que inclui o da marca FreeStyle Libre®), com consulta pública. Em relatório preliminar², "A Conitec recomendou inicialmente, por maioria simples, a não incorporação, ao SUS, do Sistema Flash de monitorização da glicose por escaneamento intermitente para o monitoramento da glicose em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e 2. Esse tema foi discutido durante a 132ª Reunião Ordinária da Comissão, realizada nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2024." Na referida reunião, o Comitê de Produtos e Procedimentos considerou "as incertezas no horizonte temporal do modelo econômico, bem quanto em sua análise de sensibilidade".

Pois bem. Nos termos do Tema 1.234 do STF supramencionado, deverá ainda ser analisado se o autor demonstrou a impossibilidade de substituição por outro medicamento das listas do SUS e protocolos clínicos; se o autor comprovou a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco com base em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise), se o laudo médico fundamentado atesta a imprescindibilidade clínica do tratamento e se o autor demonstrou a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento.

No caso em tela, todavia, não foi apontada ilegalidade na negativa de fornecimento e na atuação da CONITEC. Constata-se a existência, veracidade e legitimidade dos motivos apontados no ato administrativo como fundamentos para a sua prática, ao fundamento de que o arsenal terapêutico à época disponibilizado no SUS é suficiente para atender às necessidades dos portadores da doença.

Portanto, há óbice ao pleito autoral, eis que, sem incursão no mérito do ato administrativo, não se vislumbra irregularidade procedimental ou de ilegalidade na negativa na decisão da CONITEC, que apontou motivo existente, real e legítimo de acordo com os parâmetros construídos pelo STF para não incorporação do fármaco pleiteado no âmbito do SUS.

Outrossim, não foi demonstrada a negativa de fornecimento dos medicamentos ou tratamentos na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral.

Com efeito, diante da ausência de demonstração dos requisitos necessários e excepcionais para deferimento de medicamentos pelo Poder Judiciário, tem-se pela improcedência do pedido.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER e NEGAR PROVIMENTO** ao recurso da parte autora, de forma a manter a sentença proferida pelo juízo de origem. Sem condenação ao pagamento das custas, haja vista a isenção de que goza a parte recorrente, pelo benefício da gratuidade de justiça (art. 4º, II, da Lei 9.289/96). Condene a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, valor este que terá sua exigibilidade suspensa, haja vista tratar-se de beneficiário da gratuidade de justiça. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto.

1. <https://saude.prefeitura.rio/programa-de-hipertensao-e-diabetes/>

2. <https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2024/relatorio-preliminar-sistema-flash-cp-69>